

1501927-02.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501927-02.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501927-02.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145639/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, CA1754-1/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 2145639 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAQUE PEREIRA ASSUNÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Vistos.

I - RELATÓRIO

ISAQUE PEREIRA ASSUNÇÃO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 22h30, na Rua Doutor Carlos Alberto Morilha, Ilha Caraguatá, nesta cidade e comarca de Cubatão, ISAQUE PEREIRA ASSUNÇÃO, qualificado à fl. 08, trazia consigo, para fins de tráfico, 26 "pinos" contendo cocaína, pesando 0,35 gramas, entorpecentes que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação preliminar de fls. 15/16, sem autorização legal e em

desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, o denunciado encontrava-se na via pública, em poder das substâncias ilícitas acima descritas, a fim de distribuí-las a terceiros interessados. Policiais Militares efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos, oportunidade em que avistaram um grupo de pessoas e um indivíduo mais afastado, na posse de uma sacola plástica de cor verde nas mãos, o qual passou a caminhar, denotando comportamento suspeito. Ato contínuo, os milicianos desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem do indivíduo, o qual foi identificado como ISAQUE. Revistado, na posse do denunciado foi apreendida a sacola verde, contendo em seu interior as porções de drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), em cédulas diversas. Indagado, informalmente, o denunciado confessou a prática da mercancia ilícita no local há cerca de duas semanas, esclarecendo que os valores apreendidos eram provenientes do tráfico drogas. O denunciado foi preso em flagrante. Diante da quantidade, variedade das drogas encontradas, o modo de acondicionamento delas, a apreensão de quantia em dinheiro e das circunstâncias da abordagem policial, conclui-se que aquelas se destinavam à distribuição a terceiros. A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2022 (fls. 82/86). O acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 108/111). Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da ilicitude das provas colhidas contra o réu. É o breve relatório. Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado. Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais. Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC – e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP – passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 “representa uma nova política na seara das drogas” (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: “todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados” (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe

25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: termo de depoimento (fls. 03/07), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 15/16), relatório final (fls. 50/52), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciará.

Vejamos:

Em solo policial, a testemunha RUDNEY PEREIRA CRUZ DE OLIVEIRA disse que “Por volta das 22h30 de hoje, o depoente encontrava-se de serviço juntamente com seus colegas CB-TEODORO e SD-PM CARLOS realizando patrulhamento pelo bairro Ilha Caraguatá, nesta cidade e quando transitavam pela Rua Fued Faráh avistaram um grupo de pessoas na praça existente no cruzamento das ruas Dr. Carlos Roberto Morilhas com José Cascardi . Assim que passaram pela praça, notaram que havia um rapaz mais afastado daquelas pessoas com uma sacola plástica verde nas mãos, com volume no seu interior. Ao perceber a presença da viatura no local, tal rapaz passou a caminhar em direção às demais pessoas que ali estavam, deixando de forma nítida a intenção de evitar uma eventual abordagem. Diante desse comportamento e pelo fato de estar com uma sacola plástica nas mãos, o depoente e seus colegas entenderam que havia fundada suspeita para realizarem a abordagem. Que então desembarcaram da viatura e abordaram o suspeito, determinando que levasse as mãos à cabeça. O suspeito inicialmente relutou em levar a mão à cabeça, mas acabou concordando em seguida .O depoente retirou a sacola plástica verde que estava nas mãos do suspeito, verificando que havia no seu interior 26 (vinte e seis) cápsulas plásticas contendo cocaína e a quantia de R\$229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em cédulas diversas. Em busca pessoal nas vestes do suspeito, o SD-PM CARLOS localizou no bolso direito da sua bermuda, a quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) .O suspeito não portava documentos e se identificou como ISAQUE PEREIRA ASSUNÇÃO. Indagado sobre a destinação da droga encontrada em seu poder, ISAQUE informou que realmente estava traficando drogas pelo local há cerca de duas semanas e que a quantia encontrava-se no seu bolso era proveniente das vendas de droga realizadas até aquele momento. Diante do ocorrido, deram voz de prisão a ISAQUE e o algemaram. Assim que iriam colocá-lo na viatura, mesmo algemado, ISAQUE empreendeu fuga em direção à rodovia. O depoente e o CB-PM TEODORO seguiram no encalço de ISAQUE e o detiveram a cerca de 100 (cem) metros do local de onde havia fugido. Assim que foi detido pelo depoente e pelo CB -PM TEODORO, ISAQUE passou a dizer que queria conversar, dando a entender que iria oferecer algum suborno, mas sem efetivamente oferecer qualquer quantia ou vantagem. Que diante de todo o ocorrido, conduziram ISAQUE até esta unidade policial” (fls. 04/05).

Em solo policial, o condutor e testemunha CARLOS HENRIQUE FERNANDES CALADO disse que “Por volta das 22h30 de hoje, o depoente encontrava-se de serviço juntamente com seus colegas CB-TEODORO e SGT-PM RUDNEY realizando patrulhamento pelo bairro Ilha Caraguatá, nesta cidade e quando transitavam pela Rua Fued Faráh avistaram um grupo de pessoas na praça existente no cruzamento das ruas Dr. Carlos Roberto Morilhas com José Cascardi . Assim que passaram pela praça, notaram que havia um

rapaz mais afastado daquelas pessoas com uma sacola plástica verde nas mãos, com volume no seu interior. Ao perceber a presença da viatura no local, tal rapaz passou a caminhar em direção às demais pessoas que ali estavam, deixando de forma nítida a intenção de evitar uma eventual abordagem. Diante desse comportamento e pelo fato de estar com uma sacola plástica nas mãos, o depoente e seus colegas entenderam que havia fundada suspeita para realizarem a abordagem. Que então desembarcaram da viatura e abordaram o suspeito, determinando que levasse as mãos à cabeça. O suspeito inicialmente relutou em levar a mão à cabeça, mas acabou concordando em seguida. O SGT-PM RUDNEY retirou a sacola plástica verde que estava nas mãos do suspeito, verificando que havia no seu interior 26 (vinte e seis) cápsulas plásticas contendo cocaína e a quantia de R\$229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em cédulas diversas. Em busca pessoal nas vestes do suspeito, o depoente localizou no bolso direito da sua bermuda, a quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta reais). O suspeito não portava documentos e se identificou como ISAQUE PEREIRA ASSUNÇÃO. Indagado sobre a destinação da droga encontrada em seu poder, ISAQUE informou que realmente estava traficando drogas pelo local há cerca de duas semanas e que a quantia encontrava-se no seu bolso era proveniente das vendas de droga realizadas até aquele momento. Diante do ocorrido, deram voz de prisão a ISAQUE e o algemaram. Assim que iriam colocá-lo na viatura, mesmo algemado, ISAQUE empreendeu fuga em direção à rodovia. O CB-PM TEODORO e o SGT-PM RUDNEY seguiram no encalço de ISAQUE e o detiveram a cerca de 100 (cem) metros do local de onde havia fugido. Após retornarem com ISAQUE, o CB-PM TEODORO e o SGT-PM RUDNEY informaram que ISAQUE, assim que foi novamente detido, passou a dizer que queria conversar com eles, dando a entender que iria oferecer algum suborno, mas sem efetivamente oferecer qualquer quantia ou vantagem." (fls. 02/03).

Em Juízo, disse que o Réu estava afastado das pessoas e estava com uma sacola plástica das pessoas. Quando o Réu visualizou a viatura começou a se direcionar para o local onde havia mais pessoas. Foi dada então voz de abordagem. O Réu relutou, acretidando que possivelmente estaria armado. O Réu estava em posse de uma sacola com droga. No interior da sacola havia dinheiro trocado. O Réu confessou informalmente a prática do tráfico. Não conhecia o Réu, mas um colega lembrou que o sujeito estava em outro ponto de traficância, em uma outra ocasião. A droga era cocaína, uns 20 (vinte) e poucos pinos de cocaína. O dinheiro era em cédulas diversas. Salvo engano o Réu confessou que estava traficando há algumas semanas. Em solo policial, a testemunha MARINHO TEODORO DA SILVA disse que "Por volta das 22h30 de hoje, o depoente encontrava-se de serviço juntamente com seus colegas SGT-PM RUDNEY e SD-PM CARLOS realizando patrulhamento pelo bairro Ilha Caraguatá, nesta cidade e quando transitavam pela Rua Fued Faráh avistaram um grupo de pessoas na praça existente no cruzamento das ruas Dr. Carlos Roberto Morilhas com José Cascardi. Assim que passaram pela praça, notaram que havia um rapaz mais afastado daquelas pessoas com uma sacola plástica verde nas mãos, com volume no seu interior. Ao perceber a presença da viatura no local, tal rapaz passou a caminhar em direção às demais pessoas que ali estavam, deixando de forma nítida a intenção de evitar uma eventual abordagem. Diante desse comportamento e pelo fato de estar com uma sacola plástica nas mãos, o depoente e seus colegas entenderam que havia fundada suspeita para realizarem a abordagem. Que então desembarcaram da viatura e abordaram o suspeito, determinando que levasse as mãos à cabeça. O suspeito inicialmente relutou em levar a mão à cabeça, mas acabou concordando em seguida. O SGT-PM RUDNEY retirou a sacola plástica verde que estava nas mãos do suspeito, verificando que havia no seu interior 26 (vinte e seis) cápsulas plásticas contendo cocaína e a quantia de R\$229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em cédulas diversas. Em busca pessoal nas vestes do suspeito, o SD-PM CARLOS localizou no bolso direito da sua bermuda, a quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta reais). O suspeito não portava documentos e se identificou como ISAQUE PEREIRA ASSUNÇÃO. Indagado sobre a destinação da droga encontrada em seu poder, ISAQUE informou que realmente estava traficando drogas pelo local há cerca de duas semanas e que a quantia encontrava-se no seu bolso era proveniente das vendas de droga realizadas até aquele momento. Diante do ocorrido, deram voz de prisão a ISAQUE e o algemaram. Assim que iriam colocá-lo na viatura, mesmo algemado, ISAQUE empreendeu fuga em

direção à rodovia . O depoente e o SGT-PM RUDNEY seguiram no encalço de ISAQUE e o detiveram a cerca de 100 (cem) metros do local de onde havia fugido. Assim que foi detido pelo depoente e pelo SGT-PM RUDNEY, ISAQUE passou a dizer que queria conversar , dando a entender que iria oferecer algum suborno, mas sem efetivamente oferecer qualquer quantia ou vantagem . Que diante de todo o ocorrido, conduziram ISAQUE até esta unidade policial” (fls. 06/07).

Em Juízo, reiterou a narrativa prestada em solo policial, corroborando com a versão apresentada por seu colega de farda.

Em solo policial, o acusado ISAQUE PEREIRA ASSUNÇÃO disse que “É usuário de cocaína e maconha há um ano. Que a droga apreendida é de sua propriedade e não se destinava ao tráfico, mas sim, para seu consumo pessoal. Que havia acabado de adquirir a droga, quando policiais militares o abordaram na praça. Que durante a abordagem, o interrogando acabou por dizer aos policiais que estava traficando, porque estava com medo de que eles o prejudicassem de alguma forma. Que a quantia em dinheiro apreendida é decorrente de sua rescisão de contrato de trabalho ocorrida no dia 22 de abril de 2022, pois trabalhava como ajudante geral na Elo Construções em Cubatão/SP” (fls. 08).

Interrogado em Juízo confessou a prática da traficância. Disse que está muito arrependido. Quer recomeçar uma nova vida. Não é usuário de drogas. Mentiu na delegacia de polícia quando disse que era usuário de drogas, pois estava muito nervoso e não queria ser preso. Quando menor foi internado na Fundação Casa porque praticou roubo de um picolé. Estava há umas duas semanas praticando o tráfico de drogas pois foi demitido de seu trabalho na Elo Construções. Precisava do dinheiro para auxiliar sua avó. Estava vendendo apenas cocaína. Ganhava em torno de R\$ 50 reais por dia.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia, notadamente pela confissão do Réu em juízo. Ademais, a comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais civis deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades

fundamentais" (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre). Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perluastra que "toda pessoa poderá ser testemunha". Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, "a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação" (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98). A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP). Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes. Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficiente para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais. Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); "...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)." (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos. Dúvida não há acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Os relatos comprovam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sobretudo porque se trata de delito de tipo misto alternativo, em que a prática de apenas um dos verbos constantes no preceito primário é bastante para a sua caracterização.

Nos termos do art. 28, § 2º da Lei de Regência, notadamente as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denota-se que o acusado, de forma deliberada,

guardava e tinha em depósito drogas – verbos nucleares do preceito primário contido no art. 33 -, em elevadíssima quantidade, que seriam distribuídas pelo estado, pelo que é nítida a existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Cumprido ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar – que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consumar-se. Assim, o ato de “guardar” é apenas uma das condutas que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que o réu seja encontrado no momento que realiza a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, o acusado foi abordado em razão de uma investigação policial já instaurada há meses.

Logo, é inviável se cogitar a absolvição por falta de provas ou negativa de autora do acusado em relação à imputação da prática do delito em comento. Igualmente não há que se falar em atipicidade da conduta.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pelo Réu.

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do Réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, “não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta. b) Antecedentes: o réu NÃO ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do

tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante da menoridade penal (art. 65, inc. I do CP), pois a época do fato o réu possuía 18 anos (RG 53878220, nascimento em 24.10.2003 - fls. 29), além da confissão (art. 65, inc. III, alínea "d" e súmula 545 do STJ), que foi voluntária e integral. Como a sanção já foi fixado no mínimo legal mantenho-a no patamar já fixado (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria penal, existente a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.346/06. Embora não tenha comprovado ocupação lícita, não foi demonstrado durante a instrução criminal que estava se dedicando a atividades criminosas, malgrado o próprio Réu assentar que estava praticando o tráfico da localidade há cerca de duas semanas, ou pertencia a organização criminosa - ônus que competia à acusação (art. 156 do CPP) -. Portanto, possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11343/06, sob pena de se esvaziar por completo a aplicação da causa redutora e de violação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou a participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra in dubio pro reo" (STF, HC 103225-RN, 2ª T. rel. Min. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u). No mesmo sentido, também do c. STJ: HC 185331-RJ, 5ª T. rel. Min. Jorge Mussi, 14.02.2012, v.u).

Assim sendo, levando-se em consideração as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, diminuo a pena no patamar máximo de 2/3 (nesse sentido: STF com repercussão geral no ARE 666.334, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06/05/2014).

Reprimenda definitiva, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto ausente informações acerca da situação econômica do Réu (art. 49, § 1º c/cart. 60 do CP).

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Por sua vez, com relação à almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena.

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Nessa linha, insta consignar entendimento recentemente exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de julgamento do HC 118.533, por maioria de votos, decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06), por veemente desproporcional.

Tendo em vista as condições pessoais do acusado e natureza do ilícito praticado, consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em

duas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade -, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e à limitação de fins de semana, inexistindo razão impeditiva a tal. Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda imposta (art. 33, § 1º, alínea "c" e § 2º, alínea "c"), frente ao quantum fixado e às condições pessoais do réu, aqui já consideradas, notadamente sua primariedade, confissão e menoridade penal relativa.

VI - PERDIMENTO DE BENS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Amplamente demonstrado, que os bens apreendidos nos autos, eram utilizados para a prática de tráfico de drogas, de rigor o decreto de perdimento dos mesmos. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 13/14) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

VII - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 387, § 2º DO CPP

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quando à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais. O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2º, letras "a", "b" e "c", do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2º, do CP estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência do acusado).

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno

da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.^a Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Não há como, na fase de cognição, aferir tais requisitos, especialmente o subjetivo.

Note-se que a execução penal não se destina apenas à concessão de benefícios, de pois de certo lapso temporal, pois ela envolve um juízo de adequação do condenado à sociedade, de modo harmônico e integrado (art. 1º, LEP).

Causa insegurança simplesmente contar o tempo em que o réu está provisoriamente preso e, apenas com base nisso, fixar regime prisional mais brando, sem levar em conta todas as condicionantes para sua integração à sociedade, de modo harmônico e, repita-se, integrado.

Em suma: esta não é a sede de aferição dos requisitos para uma suposta progressão de regime. Isso compete ao Juiz das Execuções Criminais, definido previamente nas leis processuais (CPP e LEP).

VIII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ISAQUE PEREIRA ASSUNÇÃO, qualificado a fls. 08, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado ao acusado, defiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP.

Expeça-se alvará de soltura.

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

Tratando-se de dinheiro e bens apreendido (fls. 13/14) em decorrência de Tráfico de drogas, DECRETO O PERDIMENTO dos mesmos em favor da UNIÃO (art. 91 do CP, art. 63, § 1º da Lei 11.343/2006 e Provimento 20/2006-CGJ), considerando que o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é mandamento de criminalização insculpido no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República; com base no qual, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 638.491/PR, julgado em 17/05/2017, foi firmada pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, a tese de que o perdimento deve ocorrer "sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade (...) ou qualquer outro requisito" (tema 647).

Proceda-se à destruição das drogas (art. 72 da Lei 11.343/06).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila "acompanhamento de preventiva decretada", para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Após o trânsito em julgado:

a) lance-se o nome do Réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);

b) intím-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);
c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);
d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;
e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.
f) Oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se caso.
g) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e a Secretária Nacional Antidrogas, para providências cabíveis, se caso.
Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).
Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário. Saem os presentes intimados.

Cubatão, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA